Федеральная Антимонопольная Служба

(/)

База решений и правовых актов

Свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства ради будущего России

Постановление №РВ-08/1262 ПОСТАНОВЛЕНИЕ о назначении административного наказания по де... от 11 февраля 2025 г.

Вид документа

Постановление (/?type=1&category=46096)

Дата регистрации

11.02.2025 (/?type=1&start_date=11.02.2025&finish_date=11.02.2025)

Управление

Татарстанское УФАС России (/?type=1&divisions=eea49087-10bb-4901-be60-f9c5aacb5aa9)

Сфера деятельности

Не указана

Дело

Дело №016/04/14.3-1900/2024 дело №016/04/14.3-1900/2024 об административном правонарушен... (/cases/290e5486-3983-418e-9c28-6e0fe90c0311/)

Процедура

КоАП (/?type=0&procedure=43003)

Приложения

Отсутствуют

Текст документа

Сохранить как PDF (/generate_pdf/6ee545ab-6260-487c-bdd3-7d8e576ac96a/)

Исх. №РВ-08/1262 от 11.02.2025 г.

Я, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан <...> – [должностное лицо], рассмотрев протокол и материалы дела №016/04/14.3-1900/2024 об административном правонарушении, возбужденного в отношении юридического лица – ООО «Агроторг» (ИНН: 7825706086, ОГРН: 1027809237796, КПП: 784101001, дата регистрации: 10.12.2002, место регистрации: 191025, г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 90/92) по факту нарушения требований части 1 статьи 18 Федерального закона от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон «О рекламе»), ответственность за которое предусмотрена частью 4.1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

в присутствии представителя ООО «Агроторг» по доверенности <...>,

УСТАНОВИЛ:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (далее – Управление, Татарстанское УФАС России) на рассмотрение поступило обращение от <...> (вх. № 8357/ж от 05.08.2024 г.) о распространении 03.08.2024 года в 09 часов 03 минут на телефонный номер заявителя <...> без предварительного его согласия посредством телефонного сообщения с буквенного номера «Pyaterochka».

Фотоизображение представлено ниже:

<...>

В пункте 1 статьи 3 Закона «О рекламе» дано понятие рекламы — это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Согласно Приказу, ФАС России от 14.11.2023 № 821/23 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований "Понятие рекламы"» Федеральный закон «О рекламе» не распространяется на информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законом. (пункт 2 части 2 статьи 2 Федерального закона «О рекламе»).

Поскольку посредством сетей электросвязи может направляться не только реклама, но и иные виды информации, необходимо учитывать следующее.

С учетом части 2 статьи 2 Федерального закона «О рекламе», а также пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе»» не может быть квалифицирована в качестве рекламы информация, которая хотя и отвечает перечисленным критериям, однако обязательна к размещению в силу закона или размещается в силу обычая делового оборота. То обстоятельство, что информация, обязательная к размещению в силу закона или размещенная в силу обычая делового оборота, приведена не в полном объеме, само по себе не влечет признания этой информации рекламой.

Доведенная до сведения заявителя информация не относится к категории той информации, на которую Закон «О рекламе» не распространяет свое действие в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона «О рекламе». В частности, она не является справочно-информационным и аналитическим материалом (обзором внутреннего и внешнего рынков, результатом научных исследований и испытаний), не имеющим в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой.

Вместе с тем распространяемая посредством SMS-сообщений или PUSH-уведомлений информация о дополнительных услугах, предлагаемых операторами сотовой связи абонентам, с которыми у них заключен договор на оказание услуг, может рассматриваться в качестве рекламы, если такая услуга выступает в качестве объекта рекламирования.

Согласно информации, размещенной на сайте https://5ka.ru/feedback/faq/category/141fdd86-dadc-4af8-981d-594d957ed11e Апельсин — это новый сервис лояльности, который объединил лидеров рынка самых востребованных категорий: «X5 Клуб»; сервис «Пакет»; Альфа-Банк; билайн; АльфаСтрахование.

Апельсин даёт клиентам «Пятёрочки» и «Перекрёстка» возможность совершать покупки с кешбэком более 20%. Сервис объединяет всех партнёров единой валютой лояльности — Апельсинками.

Апельсинками можно оплатить часть стоимости покупок по курсу 10 Апельсинок = 1 ₽.

Чтобы списать Апельсинки, достаточно:

предъявить карту лояльности кассиру и сказать, что хотите списать кешбэк;

на кассе самообслуживания нажать соответствующую кнопку перед оплатой покупки.

Условия зависят от того, где вы хотите оплатить:

В «Пятёрочке» Апельсинками можно оплатить до 50% стоимости покупки, но нельзя потратить больше 2000 Апельсинок за один раз.

В «Перекрёстке» — до 30% в розничных магазинах и до 50% в доставке, но не более 3000 Апельсинок за один раз.

в «Много лосося» Апельсинками можно оплатить до 50% от стоимости заказа.

во «Vprok.ru Перекрёсток» — до 30% от стоимости заказа и до 6000 Апельсинок за одно списание.

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Для признания информации рекламой необходимо ее соответствие признакам рекламы, перечисленным в пункте 1 статьи 3 Федерального закона «О рекламе».

При этом под неопределенным кругом лиц понимаются те лица, которые не могут быть заранее определены в качестве получателя рекламной информации и конкретной стороны правоотношения, возникающего по поводу реализации объекта рекламирования.

Таким образом, под рекламой понимается определенная не персонифицированная информация, направленная на продвижение определенного объекта рекламирования, даже если она направляется по определенному адресному списку.

На основании изложенного, Татарстанское УФАС России приходит к выводу, что целью направления рассматриваемого сообщения является привлечение внимания потребителей к магазинам «X5 Клуб» путем направления им информации о получении баллов «Апельсинок», а также стимулирование потребителей для совершения покупок в магазине «X5 Клуб».

Рассматриваемая информация, которая доводилась до сведения Заявителя посредством сообщений на номер телефона <...> 03.08.2024, является рекламой, поскольку отвечает всем квалифицирующим признакам рекламы:

- информация распространена на электронную почту по сети электросвязи, а именно посредством использования подвижной радиотелефонной связи.

Объектом рекламирования в рассматриваемом случае является как непосредственно само ООО «Агроторг», так и программа лояльности «X5 Клуб» «Апельсинки». При этом рекламная информация направлена не на использование накопленных баллов (апельсинок), а на совершение покупок с последующим их начислением с ограниченным периодом времени, в течении которого они могут быть использованы.

Согласно информации представленной ПАО «Вымпелком (вх.№9463 от 02.09.2024) буквенный номер «Pyaterochka» принадлежит ПАО «Мегафон».

Согласно информации представленной ПАО «Мегафон» (вх.№9976 от 17.09.2024) отправка рассматриваемого сообщения была осуществлена ПАО «Корпоративный центр Икс5» на основании заключенного с ПАО «Мегафон» договора.

В рамках вышеуказанного договора ООО «Корпоративный центр Икс5» является лицом, определяющим объект рекламирования, круг получателей рекламы и использующее для распространения рекламы, услуги, оказываемые ПАО «Мегафон».

27 сентября 2024 г. в адрес Управления поступили пояснения ПАО «КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5» (вх.№10434 от 27.09.2024) исходя из которых следует, что Общество является управляющей компанией ООО «Агроторг» на основании решения от 03.07.2024 и договора о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации от 05 марта 2019 г. ФТС «Пятерочка» принадлежит ООО «Агроторг». В рамках своих полномочий ПАО «КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5» осуществляет функции по руководству текущей деятельности ООО «Агроторг», при этом деятельность по реализации и продвижению товаров, взаимодействию с потребителем, направлению рекламных рассылок осуществляется непосредственно ООО «Агроторг».

Управлением был отправлен запрос в адрес ООО «Агроторг». Общество представило согласие абонента на получение рекламы в следующем виде:

<...>

Также согласно пояснениям Общества текст смс рассылок и список получателей, направляемых потребителям, утверждаются сотрудником ООО «Агроторг».

16 октября 2024 г. в адрес Управления поступили пояснения ООО «Агроторг» (вх.№11121) исходя из которых следует, что в ООО «Агроторг» утверждены и действуют программы лояльности «X5 Клуб» (далее – Программа) для участия в Программе необходимо получить Карту и зарегистрироваться в Программе в соответствии с правилами ее проведения. <...> была получена и зарегистрирована карта 15 мая 2019 г. в 9 часов 53 минуты.

Информация из профиля пользователя <...>.

<...>

С момента регистрации в Программе «X5 Клуб» Участник вступает во взаимоотношения с Оператором Программы, полностью и безоговорочно принимает настоящие Правила, обязуется их выполнять и имеет право на получение Привилегий в соответствии с настоящими Правилами.

В соответствии с п. 3.9. Программы, осуществив регистрацию в Программе и согласившись с Правилами (приняв Правила) в соответствии с условиями п. 3.4. настоящих Правил, Участник соглашается на получение от Оператора Уведомлений, предусмотренных настоящими Правилами. Участник может настроить получение Уведомлений в Личном кабинете.

Согласно 3.10. Программы согласие на получение от Оператора рекламы (рекламных сообщений) может быть выражено Участником в любой момент времени при регистрации или после регистрации в Программе, в т. ч. при использовании Мобильного приложения. Участник, предоставивший согласие на получение рекламы, вправе в любой момент отказаться от получения рекламных сообщений по одному, нескольким или всем каналам связи одним из следующих способов:

• в Личном кабинете Мобильного приложения;

• путем обращения на Горячую линию.

Согласия пользователей на получение смс рассылки, рекламы из личных кабинетов участников программы выгружаются в программу Hive и профиль лояльности пользователя clm5_customers.

<...>

Пояснения по информации из базы данных Hive:

- строка sms_permission _flg_tc5: true - подтверждает наличие согласия у клиента на получение

уведомлений по смс.

- строка permission_adverts_flg_tc5: true - подтверждает согласие на получение рекламы.

«Permission» - переводится, как «разрешение»

«True» – переводится, как «положительный»

Также ООО «Агроторг» представлено согласие на получение рекламы и уведомлений по смс из профиля лояльности пользователя clm5_customers:

<...>

Согласие на рассылку рекламы (cus_permission_adverts)

Коммуникация через SMS (cus_permission_sms)

Согласия участников программы на получение смс рассылки, рекламы из личных кабинетов пользователей хранятся в программе Hive и профиле лояльности пользователя clm5_customers.

31 октября 2024 г. <...> было пояснено, что регистрацию в программе ООО «Агроторг», а также ввод персональных данных не производил, что подтверждаются видеозаписью, приобщенной к материалам дела.

13 ноября 2024 г. в адрес Управления поступили письменные пояснения ООО «Агроторг» (вх.№12307) исходя из которых следует, что на сегодняшний день отсутствует техническая возможность предоставления сведений о верификации пользователя <...> 15 мая 2019 г. в связи с длительным промежутком времени с указанной даты.

Согласие на получение рекламных материалов предоставляется пользователями при регистрации в программе лояльности «X5 клуб». Для регистрации в программе лояльности согласие на получение рекламных сообщений не является обязательным. Участник может выразить согласие путем проставления «галочки» в соответствующем чек-боксе на сайте программы либо в мобильном приложении, при обращении в Колл-Центр.

По умолчанию данный чек-бокс является пустым и не содержит предустановленной «галочки».

Регистрация в программе лояльности осуществляется одним из трех способов

- На сайте программы.

- В мобильном приложении.

- По телефону контакт-центра либо посредством СМС-сообщения по номеру 7775.

На текущий период ООО «Агроторг» не может представить информации каким способом заявитель выразил согласие на получение рекламных материалов, т.к. после регистрации личный кабинет гостя становится доступен как через сайт, так и через мобильное приложение независимо от способа регистрации.

08 ноября 2024 г. в адрес Управления поступил видеоматериал <...>. из содержания которого следует, что <...> регистрацию на сайте и /или в приложении не производил, персональные данные <...>. в приложении ООО «Агроторг» отсутствуют.

Фотоизображение представлено ниже:

<...>

Также с буквенного номера «Pyaterochka» на номер телефона Заявителя <...>поступили сообщения с аналогичным (схожим) содержанием 04 сентября 2024 г. и 11 сентября 2024 г.

Фотоизображение представлено ниже:

<...>

Согласно части 1 статьи 18 Закона «О рекламе», распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.

Пунктом 1 статьи 44 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» предусмотрено, что на территории Российской Федерации услуги связи оказываются операторами связи пользователям услугами связи на основании договора об оказании услуг связи, заключаемого в соответствии с гражданским законодательством и правилами оказания услуг связи

Согласно п. 35 ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее - Закон о связи) под электросвязью понимаются любые излучение, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам;работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот), средства индивидуализации

юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама (подп. 2-3 ст. 3 Закона о рекламе).

Согласно пункту 1 статьи 44.1 Закона № 126-ФЗ рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи должна осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки. Рассылка признается осуществленной без предварительного согласия абонента, если заказчик рассылки в случае осуществления рассылки по его инициативе или оператор подвижной радиотелефонной связи в случае осуществления рассылки по инициативе оператора подвижной радиотелефонной связи не докажет, что такое согласие было получено.

В пункте 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» разъяснено, что под абонентом или адресатом надлежит понимать лицо, на чей адрес электронной почты или телефон поступило соответствующее рекламное сообщение. Поскольку Закон № 38-ФЗ не определяет порядок и форму получения предварительного согласия абонента на получение рекламы по сетям электросвязи, согласие абонента может быть выражено в любой форме, достаточной для его идентификации и подтверждения волеизъявления на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя. Вместе с тем согласие абонента на получение от конкретного лица информации справочного характера, например, о прогнозе погоды, курсах обмена валют, не может быть истолковано как согласие на получение от этого лица рекламы.

Для признания надлежащим факта получения рекламораспространителем согласия абонента либо адресата на получение им рекламной информации изначально должно быть явно выраженное желание абонента, либо адресата на все получение, в том числе, посредством отметки соответствующего надлежащим образом оформленного пункта.

Согласие, полученное посредством заполнения каких-либо форм на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не позволяющих однозначно установить, кто именно дал согласие на получение рекламы, является ненадлежащим и влечет нарушение указанного требования ст.18 Федерального закона «О рекламе», поскольку не позволяет подтвердить волеизъявление конкретного абонента на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя.

В качестве доказательств получения от заявителя согласия на получение рассылки Общество представило скриншот.

Скриншот является печатной формой (текст, набор символов), из которых невозможно однозначно установить, факт совершения определенного действия, в частности факт оформления соответствующей заявки при котором предоставлено согласие на получение рекламной информации.

Также невозможно установить, кем в действительности была зарегистрирован личный кабинет физического лица и оформлена заявка.

Обществом не представлены доказательства, свидетельствующие о принятии мер к верификации заявителя (в том числе, путем получения и подтверждения <...> смс-кода на указанный в анкете номер телефона либо иным способом).

Таким образом, в материалы дела не представлено необходимых доказательств наличия согласия абонента на получение рекламы посредством рекламных звонков. Напротив, Заявителем последовательно представлены доказательства того, что принадлежащий ему номер телефона отсутствует в программе лояльности ООО «Агроторг» с надлежащей идентификацией.

В представленных ООО «Агроторг» материалах отсутствуют доказательства, свидетельствующие о наличии действий заявителя либо иных лиц, связанных с оформлением заявки (техническая информация сайта) и его идентификации (верификации). Скриншот не является надлежащим и достаточным для вывода о совершенных действиях по регистрации в программе. Указанный документ, в отсутствие доказательств, подтверждающих действие заявителя (либо иных третьих лиц) по оформлению заявки от имени заявителя, являются односторонне составленным документами, которые, при условии отрицания второй стороной участия при оформлении (составлении) таких документов, подлежат критической оценке. Со стороны заявителя продемонстрирована пластиковая карта лояльности, которая ранее им была получена непосредственно в торговом объекте ООО «Агроторг».

Согласно части 7 статьи 38 Закона «О рекламе» ответственность за нарушения части 1 статьи 18 несёт рекламораспространитель.

Рекламораспространителем является ООО «Агроторг».

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ, согласно которой нарушение установленных законодательством «О рекламе» требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи,

– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

Таким образом, действия ООО «Агроторг», выразившиеся в нарушении законодательства о рекламе, образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ.

<...>

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо ООО «Агроторг» (ИНН: 7825706086, ОГРН: 1027809237796, КПП: 784101001, дата регистрации: 10.12.2002, место регистрации: 191025, г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 90/92) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 32.2 КоАП РФ, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Согласно части 1.3-3 статьи 32.2 КоАП РФ, при уплате административного штрафа не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.

Сумма административного штрафа должна быть перечислена по следующим реквизитам:

<...>

Назначение платежа – денежное взыскание (штраф) за нарушение законодательства о рекламе, налагаемое федеральным органом государственной власти по делу №016/04/14.3–1900/2024.

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу в Татарстанское УФАС России, ул. Московская д. 55, г. Казань, 420021, тел: (843) 238-30-41, а также направив на электронную почту to16-<...>@fas.gov.ru.

Согласно части 5 статьи 32.2 КоАП РФ, при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 статьи 32.2 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, в отношении лица, не уплатившего административный штраф, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, его учреждения, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в соответствии с которой неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» постановление о наложении штрафа может быть предъявлено к исполнению в течение двух лет со дня их вступления в законную силу.

В соответствии с частью 1 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно статье 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

<...> – [должностное лицо]

Связанные организации

Связанные организации не указаны